

1518587-25.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA AFONSO DE ALMEIDA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... consigo" substância entorpecente, com o intuito de tráfico. Conquanto a tipicidade dessa conduta prescindida da demonstração da prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente a terceiro, sua subsunção à descrição legal tornar-se-á ainda mais evidente na hipótese de haver flagrância também dessa circunstância. Tráfico de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1518587-25.2022.8.26.0228 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 24 de outubro de 2022, faço estes autos conclusos ao(a) MM(a). Juiz(a) de

Direito o(a) Dr(a). FERNANDA AFONSO DE ALMEIDA. Eu, _____, subscrevi.

SENTENÇA

Processo nº:

1518587-25.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Réu:

ELCIAS NETO MELLO DE ALMEIDA e outro

Vistos.

ELCIAS NETO MELLO DE ALMEIDA e SANDRO CUNHA DA ROCHA, qualificados nos autos, foram denunciados pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, no artigo 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006 e no artigo 289, § 1º c.c artigo 61, I e artigo 69, caput, todos do CP, porque, no dia 16 de agosto de 2022, por volta das 19h30, na Avenida Ipiranga, nº 81, apartamento 1706, República, nesta Capital, agindo em associação criminosa, produziam, guardavam, vendiam e tinham em depósito, para fins de tráfico de entorpecentes, um "tijolo" (grande porção) de tetrahydrocannabinol, na forma da substância popularmente conhecida como maconha, com massa líquida total de 698,2 gramas, um "tijolo" de tetrahydrocannabinol, na forma da substância popularmente conhecida como maconha, com massa líquida total de 384,3 gramas, 16 mudas de plantas cannabis sativa L contendo tetrahydrocannabinol, na forma da substância popularmente conhecida como maconha, com massa líquida total de 11,15 gramas, um papelote contendo cocaína (cujo resultado depende de laudo definitivo - fls. 17), com massa líquida total de 18,3 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; porque, nas mesmas circunstâncias de tempo, na Avenida Ipiranga, altura do nº 1606, República, agindo em concurso e identidade de propósitos, por conta própria, adquiriam e guardavam R\$ 200,00 e moedas falsas; porque se associaram para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A denúncia foi recebida e as defesas preliminares foram apresentadas.

Durante a instrução, foram juntados documentos, bem como foram ouvidas testemunhas e os réus foram interrogados (audiovisual).

Memoriais (fls. 222/233, 251/254, 260/273, 274/280).

É o relatório.

DECIDO.

Em relação à preliminar de incompetência deste Juízo para julgamento do delito de moeda falsa, sob alegação de se tratar de matéria federal, não acolhe, diante do que dispõe o artigo 76 do CPP, cuidando-se de caso de conexão:

Art. 76. A competência será determinada pela conexão: I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras.

E, no concurso de jurisdições da mesma categoria, prepondera a do lugar da infração à qual for cominada a pena mais grave (artigo 78, II, a, do CPP); não se incorrendo em nenhuma hipótese do artigo 79 do CPP.

No mais, é de se observar o princípio constitucional da economia processual, não sendo plausível desmembrar o feito para que todos sejam ouvidos em duas esferas, para atos praticados concomitantemente.

No mérito, a ação é parcialmente procedente quanto ao delito de tráfico de drogas, por ambos os réus, e por moeda falsa, por Sandro. Vejamos.

As materialidades delitivas ficaram comprovadas pelo auto de exibição e apreensão de quatro celulares, uma balança de cozinha, 20 notas falsas de R\$ 10,00, 18,3 gramas de pó branco aparentando ser cocaína, 698,2 gramas de erva verde seca aparentando ser maconha, 384,3 gramas de erva verde seca aparentando ser maconha e 16 mudas de planta verde com características análogas de maconha (fls. 9/10); pelo auto de constatação das substâncias tetrahidrocannabinol (fls. 15/18); pelo laudo de exame químico-toxicológico, em que se atestou tratar de substância psicotrópica de uso proscrito no país (fls. 134/137); e pelo laudo pericial que atestou a falsidade de cédulas de papel moeda (fls. 202/207).

Quanto às autorias são incontestes, diante da prisão em flagrante dos agentes, na posse do entorpecente apreendido em circunstâncias de mercancia, e das moedas falsas, com o réu Sandro, conforme testemunhos policiais e civis.

Vejamos a prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O policial militar Marcos Wenceslau Almeida afirmou que a equipe recebeu disque denúncia de procurado da justiça, no Ipiranga. Deslocaram-se e contataram o porteiro para verificar se a pessoa procurada era moradora do prédio. O porteiro não localizou Sandro, alvo da denúncia, então pediram para ingressar e ver se ele estava lá. Foram ao apartamento, tocaram a campainha e Lais atendeu, falando estar hospedada temporariamente. Ela abriu a porta e viram um indivíduo correndo sentido sacada. Sandro estava do lado de fora da sacada tentando fugir pelos apartamentos vizinhos. Ele voltou e separaram os indivíduos masculinos do feminino. Em busca pessoal, nada encontraram com eles. Entre a porta e a sacada, para deter Sandro, encontraram drogas, parte em tijolo para fracionar e pés de maconha. Em busca para localizar mais objetos ilícitos, foi autorizado e encontraram 16 mudas de maconha, 1kg de maconha em tijolo e porções, cocaína, balança de precisão, celulares, dinheiro, notas falsas, que ele alegou ter recebido na mercancia e passaria para frente. Acionaram os demais ocupantes do prédio sobre a procedência dos celulares. Elcias, o outro indivíduo, falou não ter celular. Um dos celulares recebeu ligações de Rita Coelho. Ela é mãe de Elcias. Montaram o celular para ver de quem era o aparelho. Elcias falou que vendia e entregava as drogas, em mídias sociais, e pegava com Sandro. Isso foi confirmado por Sandro. Devido à demanda, foram realocados para outro DP. Não conhecia os réus. Desconhece a expressão "Atleta". Sandro assumiu que repassaria notas falsas. Havia quatro pessoas no apartamento. Alain e Lais foram ouvidos e liberados pelo delegado. Não havia fotógrafo. Usavam câmeras corporais. A denuncia continha endereço e apartamento da pessoa foragida. Alain contou que foi ao apartamento comprar droga do Sandro (fls. 19)

O policial militar Bruno Ricardo Santos Silva falou que receberam disque denúncia na referida data sobre indivíduo procurado na avenida Ipiranga, passando número e

apartamento. Deslocaram-se e contataram o porteiro para saber se o procurado Sandro residia ali. No livro de moradores não havia o nome de Sandro. Adentraram para averiguar e foi autorizado pelo porteiro. Ficou na parte de baixo na segurança. A equipe localizou Sandro e subiu para apoiar na vistoria do apartamento. Havia três homens e uma mulher. Vistoriaram o apartamento e havia na sacada pé de maconha e tijolo. Em vistoria, entre a janela e a cortina havia um celular desmontado; questionou e ninguém assumiu a propriedade. Havia chamadas de Rita, genitora de Elcias. O celular, então, era dele. Havia dinheiro, dinheiro falso. Os quatro foram conduzidos. Foi determinação da polícia civil alterar o DP da área. Era o 77º DP e encaminharam ao 4º DP, onde existe o plantão do 78º DP, por conta de reforma.

Usavam câmeras a todo momento. Sandro disse que as notas falsas tinham sido recebidas em vendas de drogas e repassaria e que era procurado. Elcias disse que estava para comprar, mas depois do celular, informou que auxiliava na entrega que faziam por redes sociais. Lais disse que morava no apartamento por ter conhecido Sandro em uma festa rave e tinha brigado com pais, mas não se envolvia, pois trabalhava com outra coisa. Não se recorda do que Alain disse (fls. 20)

A testemunha Alain Meyer Nery disse que foi buscar maconha, chegou e fumou. Foi ao banheiro e, ao sair, havia quatro policiais no apartamento. Deixaram-no sentado por duas horas e foi levado à delegacia, depois para outra. Chegou uma mulher agitada, que foi atingida por gás de pimenta. Foi comprar no apartamento de Sandro, comprou droga dele. Elcias conheceu Sandro, tinha esse contato de uma maconha boa. Foram lá comprar. No dia não o liberaram. Sempre vão às mesmas festas. Também usa cocaína. Nunca viu Elcias vendendo. Estava Lais e o fotógrafo dela. Lais vai a várias festas. Não viu quem abriu a porta aos policiais. Pagava para Sandro. Os policiais usavam câmeras. Eram fardados. (fls. 21)

A testemunha Lais Rodrigues Rocha Alves contou que estava no apartamento com seu fotógrafo e bateram na porta. Foi atender e perguntaram quem estava na casa. Apontaram a arma e foram entrando. Não autorizou e travou de medo. Ficou sentada sem reação. Morava lá por um tempo, Sandro ofereceu. Não mexe com tráfico. Pessoas iam lá comprar, mas nada na frente da depoente. Ele não deixava explícito e Sandro respeitava isso. Conheceu Sandro na rave e ele deu um local para morar. Falou da prostituição e falou por medo de ser presa, pois tem 19 anos. Elcias foi comprar droga com Aladin. Sabia que eles vendiam maconha e fumavam juntos. Sabia da maconha por conta das plantações. A depoente comprava a maconha e usava. A depoente, Aladin e Elcias saíam e usavam maconha juntos. Sandro tinha plantação. Comprava do Sandro maconha, geralmente ganhava dele. Não sabe o que aconteceu com o fotógrafo. A depoente abriu a porta, olhou o que aconteceu, perguntaram quem estava e colocaram a arma. Não esperaram falar se podia entrar ou não. Entrou uma pessoa louca depois na delegacia e jogaram spray de pimenta. Tentaram pegar as câmeras do local, mas disseram estar quebrada. Não fecharam as portas ao sair e entraram no apartamento e furtaram coisas. Para a depoente, ter a maconha ali e vender não é crime. Não reparou em câmeras pois estava com medo. Elcias ia duas a três vezes por semana no apartamento de Sandro, as vezes a depoente não estava. Não sabe o que é "atleta" e não falou isso. Não autorizou a entrada. Sabe ler. Não leu seu depoimento, mesmo preocupada (fls. 22)

Destarte, verifica-se que as provas orais e documentais coligidas aos autos não deixam dúvidas sobre a prática dos fatos descritos na denúncia pelos réus, com exceção do delito de associação ao tráfico.

E não se diga que o depoimento de policiais não merece credibilidade. Na verdade, inexistente qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos judiciais que sejam prestados por policiais, civis ou militares, até mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credencia para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chama à prestação de contas perante o Poder Judiciário, não mais lhes empreste credibilidade.

Nesse sentido, por sinal, a melhor jurisprudência: A jurisprudência do STF é no sentido de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. (STF - HC 70.237 - Rel. Carlos Velloso - RTJ 157/94).

O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando

prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. (STF - HC 73.518- 5 - Rel. Celso de Mello - DJU 18.10.96 - p. 39.846).

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (STJ - HC 608.558 RJ 2020/0217527 - Rel. Reynaldo Soares da Fonseca - j. 01.12.2020 - DJe 07.12.2020). Por isso, força convir, os depoimentos dos policiais, no caso, merecem crédito e servem, perfeitamente, para supedâneo da prolação de sentença condenatória, depoimentos estes que, em juízo, harmônicos entre si, sintonizaram-se com os depoimentos prestados extrajudicialmente e com o relato da testemunha presencial Alain, e parte com o relato da outra civil Lais.

As negativas dos denunciados não convencem, diante do farto conjunto de provas em seus desfavores. Ainda, as alegações não vieram comprovadas, na forma do que exige o artigo 156 do CPP, restando isoladas. Seguem os interrogatórios.

O réu Elcias Neto Mello de Almeida disse ter 26 anos, morar com os pais, trabalhar como assistente jurídico no escritório do pai, já ter sido processado por tráfico de drogas, estudar terceiro ano de Direito e Comércio Exterior, não ter filhos, conhecer Sandro de festa rave. Nega os fatos. Estava no apartamento, pois esperava Alain chegar e é amigo da Lais. É amigo de Sandro de longa data. Esperava mais um amigo chegar para comprar maconha. Tem diversos problemas com dicção e foi internado diversas vezes, por oito vezes, sempre teve problemas com drogas e tem distúrbios mentais. Usa medicamentos controlados. Estava sem celular. Já havia trocado na biqueira há algumas horas. Os policiais chegaram falando sobre Elvis e depois falaram Sandro. Não viu drogas. Sabia da plantação na casa por conta da psoríase que acomete Sandro. Não havia drogas no apartamento. Depois apareceram com celular e estava sem.

O réu Sandro Cunha da Rocha asseverou ter 43 anos, morar sozinho, convidou Lais para morar com ele por ter brigado com os pais, ter estudado até ensino médio, já ter sido processado, conheceu Elcias de festa rave, ter cinco filhos. Tinha plantação por ser portador de psoríase, não ter cura, ser autoimune, comprava pela internet a medicação e pesquisou, vendo processo de extração. Resolveu plantar. Em parte é verdade, havia 16 mudas em sua varanda. Iria vender, mas era uma terceira pessoa que venderia; Alain foi ao seu apartamento comprar dessa pessoa que não foi levada à delegacia. Parte foi verdade, parte não foi, não havia dinheiro, porções de maconha. As câmeras deles provam situações. Passou isso a advogada. Está arrependido de ter plantação.

Nota-se que as negativas puras e simples dos réus, bem como a imputação de conduta irregular aos policiais, sem motivo plausível ou indício de que os agentes da Lei, testemunhas, tivessem motivos para prejudicá-los, não merece crédito. Ao contrário, o que se vê dos autos são provas firmes, fortes e categóricas a indicar a necessidade de responsabilização dos acusados. Inicia-se pelo fato de Sandro ser procurado pela justiça, o que, por si só, autoriza o ingresso na residência; ainda mais porque fugia pela janela de um apartamento, em um prédio, no 17º andar, fato este inexplicável. É visível pelas imagens das câmeras captadas pelos policiais que, ao serem atendidos por Lais, no apartamento, uma pessoa fugia pela sacada, ensejando e justificando o ingresso ali, onde era visível a existência de plantio ilícito. Era certo o estado de flagrância, com pés de maconha no apartamento, assim

como drogas ali presentes, em quantidade incompatível para o uso próprio. As testemunhas civis, no mais, confirmaram que Sandro era o comerciante de entorpecentes. A traficância por Elcias, a seu turno, também ficou demonstrada, ora porque os policiais ratificaram que ele assim admitiu, fazer a venda por redes sociais, ora porque a testemunha civil Alain confirmou que seu amigo era quem tinha o contato do fornecedor e o levou até ali, intermediando a negociação de aquisição de drogas.

Ademais, ainda que os réus fossem usuários de entorpecentes, tal circunstância não exclui a possibilidade de que também se dedicam à comercialização de drogas, sendo, portanto, a análise das provas colhidas determinante da real destinação das substâncias ilícitas. No caso em questão, restou evidente que as drogas apreendidas se reservavam a terceiros, sendo descabida qualquer desclassificação. Neste sentido, é a jurisprudência pátria: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP RJTJSP 101/498).

Não se pode olvidar, a propósito, que, para a caracterização do delito previsto no artigo 33 da nova Lei de Drogas, não se exige efetivo ato de comércio, bastando que o agente tenha consigo a substância entorpecente para tal finalidade, não havendo que se falar em ocorrência somente de atos de cogitação e preparatórios. Neste sentido:

TÓXICOS - Tráfico - Caracterização - Inexistência de dúvida de que a droga apreendida com o acusado e com co-réu se destinava ao consumo de terceiros, levando-se em conta o grande volume e a forma de acondicionamento, embalada separadamente e pronta para a venda, indicando potencial destinação ao mercado nefasto - Desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado. (TJSP - AP 1.104.091-3/5 - Rel. Pinheiro Franco - j. 20.09.2007).

Tráfico de entorpecentes. Agente flagrado trazendo consigo e guardando 31,4 gramas de maconha, 1,6 gramas de cocaína sob a forma de "crack" e 0,9 gramas de cocaína em pó. Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório. Validade. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. Tráfico de entorpecentes Agente que traz consigo substância estupefaciente e é flagrado na prática de oferta gratuita ou de venda Caracterização Basta à realização do tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 o fato do agente ser flagrado "trazendo consigo" substância entorpecente, com o intuito de tráfico. Conquanto a tipicidade dessa conduta prescindida da demonstração da prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente a terceiro, sua subsunção à descrição legal tornar-se-á ainda mais evidente na hipótese de haver flagrância também dessa circunstância. Tráfico de entorpecentes Diligência na qual policiais solicitam entorpecentes aos suspeitos de tráfico Caracterização e consumação prévias do crime em razão de conduta anterior do agente consistente em "manter", "guardar" ou "ter em depósito" substância estupefaciente A ação da polícia que envolva diligência na qual policial solicita e provoca a venda de entorpecentes ao suspeito de tráfico não deve ser confundida com a situação de flagrante forjado ou provocado, uma vez que a prática do crime de tráfico já estava caracterizada pela conduta anterior do agente, que veio regida pelos núcleos verbais "manter", "guardar", "ter em depósito" etc. Eventual participação ativa de policial na dinâmica do ocorrido, consistente na solicitação de entorpecente, consiste, pois, em proceder legítimo, na medida em que não acarreta qualquer interferência externa na realização ou não do tipo penal concernente ao tráfico, que já havia se consumado, independentemente da atuação dos policiais(...). Basta

à realização do tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, com efeito, o fato do agente ser flagrado “trazendo consigo” substância entorpecente, com intuito de tráfico. Conquanto a tipicidade dessa conduta prescindida da demonstração da prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente a terceiro, sua subsunção à descrição legal tornar-se-á ainda mais evidente na hipótese de haver flagrância também dessa circunstância. (TJSP – AP 0028921-57.2016.8.26.0050 – Rel. Grassi Neto – j. 13.04.2020 – DJe 13.04.2020).

E não há que se falar em nulidade da prova, em razão da entrada dos policiais na residência onde havia a considerável quantidade de droga e plantação de tetrahydrocannabinol. Primeiro, pois os policiais asseveraram que houve autorização de ingresso por parte de Lais, ratificado pelas imagens das câmeras acopladas às fardas, em que ela abre a porta e se afasta, sentando-se no sofá. E havia situação de flagrância. Finalmente, o fato de o réu foragido, ali presente, tentar fugir pela janela do 17º andar do prédio é mais do que suficiente para autorizar o ingresso, pois configura fundadas razões para tanto. Cuida-se de crime permanente, ou seja, exceção constitucional, conforme reza a jurisprudência, em especial no RE 603616, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado em 05.11.2015:

Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.

Na mesma percepção: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova

jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. Precedentes desta Corte. 3. Na hipótese dos autos, a entrada dos policiais na residência do paciente, após denúncia anônima de que na casa estaria sendo praticado o tráfico de drogas, deu-se com o prévio consentimento do paciente, o que afasta a alegação de nulidade da busca e apreensão. 4. A alteração das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias sobre a questão demandaria o revolvimento do material fático probatório existente nos autos, o que é inadmissível na via do habeas corpus. 5. Não há como se dar guarida à pretensão da defesa de questionar a validade do consentimento dado pelo paciente para entrada dos policiais em sua residência, com fundamento apenas em alegações de que teria sido movido por um suposto temor diante da autoridade e de falta de conhecimento de seus direitos, se tais alegações não são acompanhadas de prova pré-constituída, tanto mais quando se sabe que o rito do habeas corpus não admite dilação probatória. 6. À míngua de alegação ou evidência de que a confissão do local de armazenamento da droga foi obtida mediante coação ou qualquer meio ilícito, também não há como se vislumbrar ilegalidade na confissão informal feita pelo Paciente aos Policiais Militares, indicando a localização da droga em terreno baldio, longe de sua residência. (STJ - HC 608.558 RJ 2020/0217527 - Rel. Reynaldo Soares da Fonseca - j. 01.12.2020 - DJe 07.12.2020). AGRADO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS CORRÉUS E AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA QUANTO À CONDENAÇÃO DO PACIENTE. TESE JÁ APRESENTADA E DECIDIDA NO AGRADO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA SEDE MANDAMENTAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AGRADO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 2. A Suprema Corte definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 8/10/2010). (Resp n. 1498689/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe 8/3/2018). 3. Na hipótese dos autos, conquanto sem autorização judicial, os policiais, antes de adentrarem na residência do paciente, obtiveram informações de que ali estava sendo praticado o tráfico ilegal de drogas. Modificar tal premissa fática é inviável no habeas corpus. (STJ - AgRg no HC 542.386 SP 2019/0322823-4 - Rel. Reynaldo Soares da Fonseca - j. 10.12.2019 - DJe 19.12.2019). Finalmente, reitera-se que havia foragido no apartamento e houve autorização de ingresso, registrada por áudio-vídeo: "A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada a prova enquanto durar o processo." (HC 598.051-SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma,

julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021).

Em relação ao delito de moeda falsa, o laudo de exame pericial é conclusivo de que as cédulas examinadas não se revelaram como produto de falsificação grosseira, tendo em vista que, embora não perfeitamente, ela reproduz as dimensões, textura, tonalidades, forma e disposição dos desenhos e dos dizeres das cédulas autênticas. Assim, há ofensa ao bem jurídico protegido no tipo penal em comento.

Quanto à associação ao tráfico, é mister a absolvição.

A jurisprudência ensina que para incidência no tipo penal em comento é necessário o animus associativo de duas ou mais pessoas para o cometimento de infrações, o ajuste prévio e duradouro com tal finalidade. Exigem-se os requisitos da estabilidade e da permanente – o que não se comprovou, in casu.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006" (HC 415.974/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017).

Ocorre que, em nenhum momento, as provas demonstram a caracterização do vínculo estável e permanente dos agentes Sandro e Elcias entre eles e com outros indivíduos, quesitos estes necessários para a configuração do crime de associação para o tráfico, tendo a denúncia pelo artigo 35 da Lei de Drogas se dado somente em razão da situação em que foram presos em flagrante, na posse de drogas preparadas para a venda, o que, efetivamente, não demonstra a associação.

Nesse sentido: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. NECESSIDADE PARA CARACTERIZAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LEI 11.343/06. DISPENSADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. A

jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imprescindível a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. (HC 270.837/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 30/03/2015). 2. Considerando que os fundamentos utilizados no acórdão impugnado para reconhecer que o réu praticou o delito de associação para o tráfico não se mostram idôneos, notadamente por ter dispensado o vínculo estável e permanente do recorrente com outros indivíduos, não há falar-se em caracterização do crime de associação para o tráfico. 3. Recurso especial provido para absolver o recorrente pela prática do delito de associação para o tráfico de drogas. (REsp 1713168/RJ, de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 20/03/2018).

Ainda:

APELAÇÃO CIMINAL. ART. 33, CAPUT E ART. 35 DA LEI 11343/06, COMBINADOS COM O ART. 40, INCISO IV, TODOS DA LEI 11343/06, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL - INCONFORMISMO DEFENSIVO. RELATIVAMENTO AO ART. 33, CAPUT DA LEI 11343/06 ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA POSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA. AUTORIA DUVIDOSA- PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RELATIVAMENTE AO ARTIGO 35 DA LEI 11343/06 ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ANIMUS ASSOCIATIVO NÃO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. AUSÊNCIA DO REQUISITO ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DECRETADA. Prevalecendo dúvida quanto à prática do ilícito, diante da insuficiência de provas robustas que comprovem a traficância do acusado, não havendo certeza acerca da posse da substância entorpecente descrita na denúncia, deve-se decidir em favor do mesmo, em respeito ao princípio in dubio pro reo, sendo, portanto, razoável e prudente a absolvição. De outra banda, conquanto a norma insculpida no art. 35 da Lei Antidrogas se refira à associação para a execução reiterada ou não de crimes, é de se exigir, para a caracterização do tipo em comento, a reunião estável com fins permanentemente ilícitos, sob pena de se punir a coautoria como se delito autônomo fosse. Logo, não comprovada a estabilidade da associação, a absolvição por este crime é imperativa (TJRJ – AP 0265887-85.2013.8.19.0001 – j. 19.02.2015). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO

ELEMENTO SUBJETIVO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006. INCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a caracterização do crime de associação criminosa, é imprescindível a demonstração concreta do vínculo permanente e estável entre duas ou mais pessoas, com a finalidade de praticarem os delitos do art. 33, §1º e/ou do art. 34 da Lei de Drogas (HC 354.109/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 15/09/2016, DJe 22/09/2016; HC 391.325/SP Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017). 2. Na hipótese, à míngua de um exame aprofundado do conteúdo probatório, verifica-se que o Tribunal de origem não apresentou elementos concretos que demonstrem efetivamente o animus associativo entre o paciente e outros agentes. A condenação pelo delito do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 está amparada na presunção de que, por estar traficando em local dominado por facção criminosa, o agente seria dela integrante. Assim, em decorrência da falta de comprovação de pressuposto legal – elemento subjetivo –, a absolvição do paciente é de rigor. 3. Tendo sido afastado o redutor do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 unicamente em razão da condenação pelo delito de associação, impõe-se o reconhecimento o tráfico privilegiado em benefício do ora agravado. 4. Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg no HC 556076 RJ 2020/0000538-6 – Rel. Ribeiro Dantas – j. 25.08.2020 – DJe 03.09.2020).

Passa-se à dosimetria da pena.

Na primeira fase, observando-se os elementos previstos no artigo 59 do CP e no artigo 42 da Lei de Drogas, fixam-se as penas bases no mínimo legal para o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas e para o delito do artigo 289, § 10, do CP, ou seja, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa e 3 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, em virtude da reincidência por tráfico pelos dois réus, aumentam-se as penas em 1/6, totalizando-se 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa e 3 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa. Inexistiu qualquer confissão judicial ou extrajudicial quanto à imputação descrita na denúncia, de modo que não se aplica a atenuante genérica.

Na terceira fase, não se reconhece a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º da Lei de Drogas, em virtude das reincidências.

Observa-se que o fato de se considerar a agravante na segunda etapa da dosimetria não impede que seja sopesada para analisar questão relativa ao cabimento da minorante, mormente porque a circunstância reflete ou repercute em momentos e para fins distintos, por força de dispositivos legais claros (artigo 68 do CP e artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06): Reincidência. Reconhecimento como agravante e para o afastamento da incidência da diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Admissibilidade. Bis in idem. Não ocorrência. Recurso não provido. 1. Dentro dos limites da matéria impugnada na apelação do Ministério Público, o conhecimento do tribunal ad quem é o maior possível, razão por que o redimensionamento da pena não importa em reformatio in pejus. 2. A reincidência constitui circunstância agravante (art. 61, I, CP) a ser obrigatoriamente considerada na segunda fase da dosimetria da pena (art. 68, CP), ao passo que a primariedade constitui inafastável requisito de natureza subjetiva para a aplicação da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. 3. Não havendo dupla valoração negativa da reincidência, mas, sim, estrita observância das regras legalmente aplicáveis à espécie, não há que se falar em bis in idem. 4. Recurso não provido. (STF – RHC 121598/SP – Rel. Ministro Dias Toffoli – j. 21.10.2014). Não resta caracterizado 'bis in idem' na utilização da reincidência como agravante genérica e para afastar o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, aplicável apenas ao réu primário e de bons antecedentes. Precedentes. (STF – HC 205.295/SP). Reincidência. Reconhecimento como agravante e para o afastamento da incidência da diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Admissibilidade. Bis in idem. Não ocorrência. Recurso não provido. (STF – RE com Agravo 929.416/SC – Rel. Marco Aurélio – j. 18.11.2015). Recentíssimos julgados do Superior Tribunal de Justiça não dissentem, consignando-se que: Não resta caracterizado 'bis in idem' na utilização da reincidência como causa ensejadora da não aplicação da minorante do

art.33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, bem como agravante da pena, ante expressa previsão legal. Habeas Corpus denegado (STJ – HC 148.575/SP).

E somam-se as penas dos dois delitos em relação ao réu Sandro, por se tratar de fatos e dolos diversos, na forma do artigo 69 do CP.

Fixa-se cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da falta de informações precisas sobre a situação econômica dos réus. Nos termos do disposto no artigo 33, § 2º, “a” e § 3º do CP e no artigo 384 do CPP, considerando-se as reincidências dos réus, fixa-se o regime fechado de cumprimento de pena. E por terem respondido o processo presos, não poderão apelar em liberdade. Estando ausentes os requisitos do artigo 44 do CP, pelas reincidências, deixa-se de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Permaneceu inalterada a situação fática que determinou a decretação da prisão cautelar anteriormente, presentes, ainda, os requisitos legais, não se justificando, agora que se acolheu a pretensão estatal para condenar o denunciado, ordenar sua liberação, sem prejuízo do conhecimento de eventual recurso de apelação. Consoante o artigo 387, § 2º, do CPP, mantem-se o regime prisional acima fixado, pois inexistem informações sobre o comportamento carcerário do acusado para a progressão de regime, consoante o artigo 112 da LEP. Neste prisma: TJSP – AP 0045877-82.2014.8.26.0224 – Rel. Luiz Antonio Cardoso; e TJSP – AP 0004038-54.2014.8.26.0361 – Rel. Luiz Augusto de Sampaio Arruda.

Diante do exposto, CONDENO o réu ELCIAS NETO MELLO DE ALMEIDA às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime fechado, e 583 dias-multa, no valor mínimo unitário legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006; e CONDENO o réu SANDRO CUNHA DA ROCHA às penas de 9 anos e 4 meses de reclusão, no regime fechado, e 594 dias-multa, no valor mínimo unitário legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e no artigo 289, § 1º, do CP, na forma do artigo 69, caput, do CP; e ABSOLVO ambos os réus da imputação pela prática do delito do artigo 35, da Lei n. 11.343/2006, na forma do artigo 386, VII, do CPP.

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, expeça(m) ou adite(m)-se a(s) guia(s) de execução, encaminhando-se à Vara das Execuções Criminais competente; façam-se as comunicações; atualize-se o histórico de partes; archive-se; expeça(m)-se mandado(s) de prisão, se for o caso; uma vez cumprido(s), expeça(m)-se guia(s) de recolhimento, encaminhando-se à Vara das Execuções Criminais competente; caso o(s) réu(s) não seja(m) encontrado(s), aguarde-se em escaninho próprio, cobrando-se a cada 120 dias; ou designe-se audiência para regime aberto; deverá(ão) o(s) réu(s) ser intimado(s) no último endereço onde foi(ram) encontrado(s); caso o(s) réu(s) não seja(m) encontrado(s), expeça(m)-se mandado(s) de prisão, fazendo constar que o(s) réu(s) deverá(ão) ser imediatamente apresentado(s) a este Juízo para participar da audiência de regime aberto e, após, será(ão) posto(s) imediatamente em liberdade; decorridos 90 dias do trânsito em julgado, oficie-se para destruição das moedas e notas, celulares, drogas e contraprova, balanças; fica(m) desde já o(s) réu(s) intimado(s) a pagar os dias-multa, em 10 dias a contar do trânsito em julgado, com consectários legais (Banco do Brasil, Agência 1897-X, conta 139.521-1, Titular Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo); na hipótese de quitação, abra-se vista ao Ministério Público e, após, venham conclusos para declaração da extinção da punibilidade da pena de multa; caso não seja efetuado o pagamento da multa, encaminhe-se para cobrança.

São Paulo, 24 de outubro de 2022.

FERNANDA AFONSO DE ALMEIDA
Juiz(a) de Direito